

1500520-46.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... em local com alta incidência do delito de tráfico de drogas não é suficiente, por si só, para afastar a hipótese do tráfico privilegiado. A corroborar: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500520-46.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500520-46.2021.8.26.0616 2021/000335

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066046/2021 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 16655451 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 385/21/301 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 2066046 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ALISON DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, observados os ditames da Lei n.º 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 08 de março de 2021, por volta de 21h50, na Rua Seis, próximo ao nº 01, casa "b" da via pública, no bairro Jardim Vista Alegre, na cidade de Biritiba Mirim, nesta comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, certa quantidade da droga cocaína, dividida em 05 (cinco) invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

Consta ainda, conforme narrado na denúncia, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, mas na Rua Cinco, próximo ao imóvel de nº 224 da via pública, bairro Jardim Vista Alegre, na cidade de Biritiba Mirim, nesta comarca de Mogi das Cruzes, ALISON DOS SANTOS guardava, para fornecimento a terceiros, certa quantidade da droga cocaína, dividida em 23 (vinte e três) invólucros e 01 (um) eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Houve prisão em flagrante (fls. 01 e ss), convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls.49/50.

Acusado posto em liberdade em 23/04/2021, à vista da concessão do Habeas Corpus 657878/SP pelo E.STJ (fls.109/126).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2021 (fls. 143), após defesa preliminar (fls.130/134) e respectivo aditamento em 14 de julho de 2021 (fls.186).

Citada (fls.201), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.177, 205.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.212).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls.229 e ss).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede, parcialmente, o pedido contido na denúncia.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. /01 e ss), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 15/17), laudo de exame químico toxicológico das drogas (fls. 80/81), laudo dos objetos apreendidos (fls. 153/154), bem como pela prova oral colhida.

O próprio réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confessou a prática do crime (fls.05).

Ao ser ouvido em juízo, afirmou que está arrependido. Quando os policiais abordaram o réu, ele não estava com as drogas; confirmou que já havia jogado os entorpecentes no pelo muro da testemunha. Não indicou onde havia mais drogas para os policiais, foram eles que acharam. Confirmou que havia enterrado os entorpecentes encontrados. Afirmou que estava usando as drogas e acabou vendendo algumas. Negou que o dinheiro apreendido era fruto da venda dos entorpecentes, afirmou que estava bebendo antes em um bar. Não estava vendendo drogas no momento da abordagem policial. Ainda não tinha vendido, estava com dinheiro pois estava bebendo.

No mesmo sentido da confissão do réu foram os depoimentos das duas testemunhas, ouvidas em juízo.

Com efeito, a testemunha Cristina do Nascimento afirmou em Juízo que estava dentro de casa, sua casa é murada e com o portão, não dá pra ver a rua. Recorda-se que a polícia bateu em seu portão e pediu a permissão para entrar e verificar um corredor que tem atrás da porta, pois o réu havia jogado algo dentro de seu quintal. A depoente autorizou a entrada dos policiais, que iluminaram esse corredor e recolheram o que o réu tinha jogado lá. Com isso saíram, conduziram o réu e depois buscaram a depoente para comparecer na delegacia. Viu que os policiais recolheram dinheiro, mas não sabe a quantidade, e droga, mas também não pode afirmar a quantidade.

A testemunha Marcelo dos Santos Silva, relatou em Juízo que estavam em patrulhamento no bairro já na intenção de coibir a prática de tráfico, que estava muito alta. Ao acessar a rua, o réu percebeu a presença da equipe policial e se encostou em um muro e já levou as mãos por cima da cabeça, nesse muro, e permaneceu encostado lá. Percebeu que estava escondendo algo. Fizeram a abordagem, estava o réu e outro indivíduo. A dona da casa escutou a chegada dos policiais e saiu para ver o que estava acontecendo. Nada foi encontrado com o réu. Porém, solicitou permissão para a dona da casa para que pudesse verificar se o réu tinha dispensado alguma coisa em sua residência. Assim, na parte de dentro do muro onde o réu tinha encostado, visualizou dinheiro, cocaína e um celular jogado ao solo. Indagado no momento, o réu admitiu a posse dos objetos e que havia dispensado. O depoente perguntou se havia mais drogas com o réu e ele indicou um local a beira da via,

onde tinha enterrado uma meia com uma quantidade de entorpecentes. Não se recorda como estavam embalados. Afirmou que o local dos fatos tem reincidência de tráfico de drogas, já ocorreram prisões anteriores e posteriores aos fatos, no mesmo local. Afirmou que já havia abordado o réu em outras ocasiões mas não tem inimizade com o acusado, apenas faz seu papel e em alguns momentos em que o indivíduo se comporta de forma suspeita, faz a abordagem. Não tinha nem tem nada contra o réu.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

De início, observa-se que a quantidade de droga apreendida, a variedade, sua forma de acondicionamento, dos entorpecentes, e os depoimentos colhidos já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Outrossim, o acusado confessou a prática delitiva nos exatos termos apresentados nos autos, corroborando a versão dada pelas testemunhas ouvidas em juízo. Confirmou a posse dos entorpecentes bem como que os dispensou através do muro da casa da testemunha Cristina, além de ter afirmado que, de fato, enterrou os demais entorpecentes encontrados pelos policiais. De rigor, assim, sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Lado outro, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve ser afastada, como requerido, inclusive, pelo Ministério Público, eis que não restou comprovado que o acusado, de fato, realizava a comercialização de drogas valendo-se da maior circulação de pessoas nas imediações de locais protegidos pela norma.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a majorante em comento se justifica "quando for maior a aglomeração de pessoas, e mais fácil, ágil e disseminado torna-se a mercancia da droga, razão pela qual se justifica a causa de aumento da pena" (In: Leis penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 793).

Ademais, verifica-se, pelo laudo de fls.149/152, que o local mais próximo dos fatos se trata de uma igreja, a qual não está inserida o rol da referida Lei, taxativo.

Por fim, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere da certidão e Folha de Antecedentes de fls.226/229, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual. Ademais, não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da quantidade de droga apreendida que, para os fins do benefício, não é expressiva.

Pontuo, ainda, que o fato de ter sido abordado em local com alta incidência do delito de tráfico de drogas não é suficiente, por si só, para afastar a hipótese do tráfico privilegiado. A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECONHECIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das condições obstativas da causa especial de redução pelo tráfico privilegiado. 2. Na hipótese, o recorrente foi condenado por trazer consigo e manter em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 97 pedras de crack, pesando 14,2g e 7,9g de maconha, tendo sido ressaltado o porte de arma de fogo municada. 3. Tratando-se de agente primário, e considerando a apreensão de quantidade não significativa de entorpecentes, a simples menção à apreensão da arma municada na posse do agente em local conhecido como ponto de tráfico, desprovida de outros elementos adicionais que evidenciem a dedicação do agente ao tráfico

ilícito, não é suficiente para afastar a aplicação o benefício. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 719258 RS 2022/0017520-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, sendo o réu primário, sem antecedentes atestados nos autos, bem como não se tratando de quantidade expressiva nem variedade de entorpecentes, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não obstante a confissão do réu, nos termos do disposto na Súmula nº 231 do STJ, como a pena já foi fixada em seu mínimo legal, ela não deve ser alterada, pois atenuantes não têm o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, não sendo o caso, porém, de redução da pena no patamar máximo legal.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10).

E “(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma – Dje 29/11/2010).

Por fim, ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG,

1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ALISON DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Tendo em vista o regime inicial fixado para o cumprimento de pena e não havendo motivos para decretar sua prisão cautelar, poderá recorrer em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quando aos bens apreendidos, determino a perda em favor da União, nos termos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA